

1500210-72.2019.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... as circunstâncias negativas atinentes ao crime de tráfico drogas, mais especificamente, natureza e a quantidade abundante da droga, além da apreensão de petrechos e insumos destinados ao tráfico de drogas que exigem a fixação do regime mais rigoroso para início do cumprimento de pena para uma correta prevenção criminal.

Considerando a pena aplicada, verifico que não se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500210-72.2019.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500210-72.2019.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2028508/2019 - 01º D.P.

TABOÃO DA SERRA, 539/2019 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS AUGUSTO ROSSI e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ofereceu denúncia em face dos réus, MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA PADILHA e MATHEUS AUGUSTO ROSSI, como incursos no artigo 33, caput, no artigo 33, §1º, inciso I, e no artigo 34, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal.

Narrou na denúncia que, no dia 29 de janeiro de 2019, por volta de 20h40, na Rua Rodrigues Alves, nº 18, Jd. Trianon, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra, os acusados, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, traziam consigo, tinham em depósito e guardavam, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes na massa líquida de 29,5kg (vinte e nove quilogramas e cinco hectogramas) de cocaína, acondicionada em invólucros plásticos; na massa líquida de 730g (setecentos e trinta gramas) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, acondicionada em 450 (quatrocentas e cinquenta) porções individuais; na

massa líquida de 174,5g (cento e setenta e quatro gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionada em 349 (trezentas e quarenta e nove) porções individuais; e na massa líquida de 7,5g (sete gramas e cinco decigramas) de cocaína na forma de pedras de crack, acondicionada em 50 (cinquenta) porções individuais; sendo estas substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os réus, tinham em depósito e guardavam insumos destinados à preparação de drogas, consistentes em 08 (oito) garrafas de líquido para refino, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Por fim, constou que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os acusados, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, possuíam e guardavam instrumentos destinados à fabricação, preparação, produção e transformação de drogas, consistentes em 02 (duas) balanças de precisão e 03 (três) peneiras, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 94/98).

Os réus Michael e Matheus foram notificados respectivamente às fls. 116/117 e 118/119 e apresentaram defesa preliminar às fls. 129/130 e 134/135.

A denúncia foi recebida aos 21 de julho de 2020 (fls. 200).

Realizada audiência de instrução foram inquiridas duas testemunhas. Em seguida os acusados foram interrogados. Ao final, o Ministério Público e as Defesas reiteraram as solicitações do laudo do exame pericial cujo objeto era o líquido existente nos oito frascos encontrados no local da abordagem (fls. 225/226).

A Defesa de Matheus requereu a juntada de documentos, algumas folhas do processo nº 1500088-19.2020.8.26.0609. A Defesa de Michael Douglas, por sua vez, juntou Declaração de Trabalho às fls. 238.

Superada a fase de diligências, as alegações finais foram convertidas em memoriais escritos.

O Ministério Público postulou a procedência parcial da pretensão acusatória, para condenar Douglas, integralmente, nos termos da exordial, bem como Matheus apenas pela prática do crime de tráfico de drogas capitulado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, por entender estarem devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva. Por outro lado, pugnou pela absolvição de Matheus atinente aos crimes previstos no artigo 33, §1º, I e artigo 34, ambos da Lei nº 11.343/06. Ao final, fez considerações acerca da dosimetria da pena de cada um dos réus (fls. 258/273).

Já as defesas, em síntese, pugnaram pela absolvição dos réus (fls. 284/286 e 288/290).

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante de fls. 01; boletim de ocorrência de fls. 02/06; auto de exibição e apreensão de fls. 15/17; laudo de constatação de fls. 32/35; laudos periciais de fls. 182/185, 186/191 e 192/196 e 253/255; e da prova oral produzida nas fases policial e judicial.

Quanto à autoria, também ficou caracterizada e recai sobre as pessoas dos réus. Senão vejamos.

Em solo policial, a testemunha e policial militar Gabriel Silva Velasco declarou que "efetuavam patrulhamento pela área dos fatos, momento em que visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita. Diante da fundada suspeita, acharam por bem abordá-los. No momento em que desembarcaram da viatura, ambos os indivíduos tentaram fugir, cada um correndo para um lado, quando então a guarnição se dividiu e conseguiu capturar ambos os indivíduos. Consignam ainda os policiais militares que uma pessoa do sexo feminino também fugiu do local, não sendo capturada. Ocorre que em posse do indiciado Matheus, fora encontrada dentro de uma mochila a quantia 243 porções de cocaína, 38 porções de crack, 165 porções de maconha, além de R\$ 456,20 em espécie. Junto ao indiciado Michael Douglas, num primeiro momento nada de ilícito fora encontrado, porém, os policiais militares desconfiados da fuga do indiciado o questionaram sobre o endereço que morava, sendo que este local é situado a metros do local da captura. Informados sobre o endereço e após o indiciado franquear a entrada dos policiais naquela residência, permissão esta

testemunhada pela pessoa de LUIZ NOGUEIRA, Rg: 45.141.691 SSP/SP, fora encontrado no interior da residência de Michael sacos contendo pó semelhante a cocaína, 285 porções semelhantes à maconha, 12 porções semelhantes à crack e 106 eppendorf's contendo porções semelhantes à cocaína. Além desta grande quantidade de entorpecente, fora encontrado naquela residência mais 3 peneiras, 2 balanças de precisão, grande quantidade de eppendorf_ s vazios e 8 garrafas contendo líquido desconhecido, provavelmente usado no preparo/refino de droga e um RG em nome de Jennifer, provavelmente aquela pessoa do sexo feminino que conseguiu fugir. Insta consignar que Michael Douglas também portava um celular da marca Samsung." (fls. 12/13).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que o local onde visualizaram os dois indivíduos no início da abordagem era conhecido como ponto de venda de drogas. Sua equipe e outra equipe fizeram o cerco e, no momento em que adentraram a viela, alguns indivíduos saíram correndo. Diante disso, correram atrás dos indivíduos, sendo que Matheus foi alcançado por um dos policiais com uma mochila, no interior da qual havia 243 (duzentas e quarenta e três) porções de "cocaína", 38 (trinta e oito) porções de "crack", 165 (cento e sessenta e cinco) porções de "maconha", além de determinada quantia em dinheiro. Michael Douglas foi alcançado pelo depoente e, em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, mas o acusado não soube explicar o motivo pelo qual começou a correr. O depoente questionou onde estava o documento do réu, que afirmou estar na sua residência, a poucos metros do local. Assim, dirigiram-se até a residência. Tinham duas casas no local. Luis Nogueira residia em uma e o Michael Douglas em outra. O mesmo corredor dava acesso às duas. O proprietário era o Luis Nogueira que alugava um dos imóveis ao Michael Douglas. O proprietário do imóvel franqueou a entrada dos agentes públicos ao corredor e Michael Douglas franqueou a entrada na casa dele. Matheus confessou que era seu primeiro dia naquele local fazendo tráfico e que foi contratado pelo seu primo, Michael Douglas. Matheus disse que na casa onde foram encontradas as drogas e os petrechos residia apenas o Michael Douglas, a esposa Jenifer e o filho do casal. No mais, disse que Matheus teria relação apenas com as drogas localizadas no interior da mochila e não com as drogas localizadas na casa, tendo sido a informação confirmada por Michael Douglas. Essa informação foi confirmada pelo Michael Douglas.

Em sede policial, a testemunha e policial militar Fabio Gomes Araujo declarou que "efetuavam patrulhamento pela área dos fatos, momento em que visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita. Diante da fundada suspeita, acharam por bem abordá-los. No momento em que desembarcaram da viatura, ambos os indivíduos tentaram fugir, cada um correndo para um lado, quando então a guarnição se dividiu e conseguiu capturar ambos os indivíduos. Consignam ainda os policiais militares que uma pessoa do sexo feminino também fugiu do local, não sendo capturada. Ocorre que em posse do indiciado Matheus, fora encontrada dentro de uma mochila a quantia 243 porções de cocaína, 38 porções de crack, 165 porções de maconha, além de R\$ 456,20 em espécie. Junto ao indiciado Michael Douglas, num primeiro momento nada de ilícito fora encontrado, porém, os policiais militares desconfiados da fuga do indiciado o questionaram sobre o endereço que morava, sendo que este local é situado a metros do local da captura. Informados sobre o endereço e após o indiciado franquear a entrada dos policiais naquela residência, permissão esta testemunhada pela pessoa de LUIZ NOGUEIRA, Rg: 45.141.691 SSP/SP, fora encontrado no interior da residência de Michael sacos contendo pó semelhante a cocaína, 285 porções semelhantes à maconha, 12 porções semelhantes à crack e 106 eppendorf's contendo porções semelhantes à cocaína. Além desta grande quantidade de entorpecente, fora encontrado naquela residência mais 3 peneiras, 2 balanças de precisão, grande quantidade de eppendorf_ s vazios e 8 garrafas contendo líquido desconhecido, provavelmente usado no preparo/refino de droga e um RG em nome de Jennifer, provavelmente aquela pessoa do sexo feminino que conseguiu fugir. Insta consignar que Michael Douglas também portava um celular da marca Samsung." (fls. 14).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não

havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que estavam em patrulhamento pelo local, já conhecido como ponto de venda de drogas e, no momento em que chegaram próximo à viela, indivíduos avistaram a viatura e empreenderam fuga a pé. Uma parte da equipe desembarcou em perseguição, sendo que a outra parte deu a volta para fazer o cerco policial. Quando o depoente deu a volta com a viatura, um indivíduo correu em sua direção e foi abordado. Em busca pessoal, no interior da mochila, foi localizada determinada quantidade de entorpecentes. Informalmente, o indivíduo confessou que era seu primeiro dia traficando naquele local e informou ter sido convidado por seu primo, de nome Michael Douglas, sendo que a intermediação era realizada por Jhenyfer, esposa de Michael Douglas. Outrossim, ele indicou mais drogas que estavam escondidas no muro. Os demais policiais que estavam a pé pela viela chegaram trazendo Michael Douglas, o qual informou que seu documento estava na sua residência, bem como que sua esposa Jhenyfer estaria no local. Assim, dirigiram-se até a casa e o dono do imóvel informou que Jhenyfer tinha recebido um telefonema e saído há poucos instantes, chorando. Michael Douglas estava com a chave da casa e franqueou a entrada dos policiais. No interior do imóvel, localizaram vários produtos e embalagens, e o réu confessou que era pago para armazenar a droga dentro da casa dele. Recordou que encontraram balança de precisão, garrafas contendo produtos químicos, peneira, material para preparo e eppendorfs vazios. Disse que era possível sentir um forte odor de produtos químicos. No mais, afirmou que apenas o acusado e a esposa residiam no imóvel, tanto que localizaram o documento de identificação dela. Não se recorda das características da mochila que estava nas costas de Matheus. Pelo que constatou, Matheus não tinha relação com a droga localizada na casa de Michael Douglas. Na fase inquisitiva, os acusados manifestaram o desejo de manterem-se em silêncio e pronunciarem-se apenas em juízo (fls. 07/08 e 09/10).

Em juízo, o acusado Matheus Augusto Rossi negou a prática do crime. Disse que estava na rua paralela à rua descrita na denúncia indo ao encontro de Douglas, quando viu os policiais entrando na comunidade. Como o local é uma área de tráfico e o depoente é negro ficou com medo. Acabou correndo e encontrou o policial Fabio que o abordou. Não tinha mochila e nem portava qualquer droga. Durante a abordagem os policiais chegaram com o Douglas. Depois disso o depoente foi levado para casa de Douglas e os policiais disseram que tinham as drogas lá dentro. Os policiais conversaram mais com o Douglas. Não chegou a entrar na casa do Douglas, ficou dentro da viatura algemado. Não viu as drogas e os petrechos. Não sabia que o Douglas morava naquela casa e nem que mexia com esse tipo de coisa. Achava que Douglas morava no mesmo local que a sogra. Posteriormente o Douglas admitiu para o depoente que morava naquele local e que mexia com drogas e pediu desculpas por envolver o depoente nisso. Douglas é seu primo. Não conhecia os policiais que efetuaram a abordagem, nem tinha nada contra eles. Não sabe dizer o porquê deles terem incriminado o depoente falsamente. Já foi abordado diversas vezes naquele local. Só teve passagem anterior como menor de idade e posteriormente houve um mal entendido com o seu empregador, mas que ficou resolvido, sendo que continua trabalhando com ele até os dias atuais.

Em juízo, o acusado Michael Douglas Oliveira Padilha admitiu a prática do crime. Disse que um amigo chamado João, que morava em Taboão da Serra, mas se mudou para a Bahia, propôs ao depoente de armazenar as drogas apreendidas na sua casa: cocaína, maconha e crack. O depoente ia receber em troca o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais). Fazia uma semana que estava guardando as drogas em sua casa. Também guardava as peneiras, balanças e as oito garrafas com líquido para refino. Apenas guardava, não embalava, pesava ou preparava a droga. Quem fazia era o João. O João não preparava as drogas na casa do depoente. Correu e não viu o Matheus correr com a mochila. Não viu a mochila. Não tem passagens. Atualmente está trabalhando como frente de trabalho. Atualmente mora com a esposa e filha de 1 ano e 8 meses.

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas é medida de rigor.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas foram uníssonos e harmônicos no sentido que os acusados estavam traficando nos locais dos fatos.

Pelos relatos desinteressados dos policiais, já que nem mesmo os acusados apontaram

ou comprovaram qualquer indício de que eles tivessem algum motivo ou interesse em acusá-los falsamente, ficou sobejamente demonstrado que o acusado Matheus trazia consigo e Douglas tinha em depósito e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Embora os réus sejam primos e haja fundados indícios de que Douglas teria convidado Matheus para a prática do tráfico, verifico não ter ficado claro se ambos tinham ciência e agiram em unidade de desígnios entre si. Ao que tudo indica, a droga apreendida com cada um foi efetuada em contextos relativamente distintos, devendo haver a devida distinção dos fatos e individualização das condutas.

Com o acusado Matheus foram localizadas 243 (duzentas e quarenta e três) porções de "cocaína", 38 (trinta e oito) porções de "crack", 165 (cento e sessenta e cinco) porções de "maconha" e R\$ 456, 20 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos) em espécie dentro de uma mochila, sem participação ou coautoria por parte de Douglas.

Já as drogas e petrechos encontradas com Douglas não guardavam relação com Matheus, o que foi, inclusive, apontado pelo próprio Ministério Público em alegações finais. Nesse contexto, destaco que na residência de Douglas foram encontrados sacos plásticos contendo grandes porções de "cocaína", 285 (duzentas e oitenta e cinco) porções de "maconha", 12 (doze) porções de "crack" e 106 (cento e seis) porções de "cocaína", bem como 03 (três) peneiras, 02 (duas) balanças de precisão, grande quantidade de eppendorfs vazios e 08 (oito) garrafas contendo líquido usado no preparo e refino de drogas, fatos confessados pelo próprio acusado, tornado indubitosa sua autoria delitiva.

Imperioso ressaltar que os acusados foram presos em local conhecido pela prática costumeira do tráfico de drogas, a quantidade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções individuais, próprias para a entrega a consumo de terceiros, a variedade (maconha, cocaína e crack), e a quantia em dinheiro apreendida, demonstrando que se destinava ao comércio ilícito de drogas.

Urge mencionar que os depoimentos prestados pelos agentes públicos gozam de credibilidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas. No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelos policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados. Nesse sentido:

"(...)Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011).

"(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.(...)" (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009)

Lado outro, entendo que o depoimento do réu Matheus restou isolado nos autos, não guardando qualquer respaldo com o que foi averiguado e comprovado em juízo.

Vale dizer que não há motivos para duvidar da versão dos fatos apresentada pelos policiais, sendo que nem mesmo a Defesa apontou a existência de qualquer motivo concreto de que estes tivessem o menor interesse em querer incriminar falsamente o réu.

Por outro lado, considerando que as drogas, insumos e petrechos atinentes ao Douglas foram apreendidos no mesmo contexto fático, sendo imperioso o reconhecimento da absorção dos crimes dos artigos 33, §1º, inc. I, e artigo 34, pelo crime do artigo 33, caput, todos da Lei de Drogas.

Em relação aos crimes tipificados nos artigos supracitados ocorre a aplicação do princípio da consunção, posto que não caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes em relação às drogas e os petrechos para sua preparação

que foram encontrados, de forma que não violam distintamente os interesses jurídicos protegidos. Nesse sentido:

"(...) Portanto, a prática do art. 33, caput, da Lei de Drogas absorve o delito capitulado no art. 34 da mesma lei, desde que não fique caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta. Deve ficar demonstrada a real lesividade dos objetos tidos como instrumentos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, ou seja, relevante analisar se os objetos apreendidos são aptos a vulnerar o tipo penal em tela. (...)"(AgRg no AREsp 303.213/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 14/10/2013)

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a parcial procedência da pretensão acusatória.

Passo à dosimetria da pena dos réus, de forma individualizada, o que faço nos termos do artigo 68 do Código Penal.

MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA PADILHA

No tocante ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal:

culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado é primário, não possuindo antecedentes criminais dignos de registro); conduta social (nada a considerar); personalidade (não há elementos para aferir eventual personalidade nociva do réu); motivos do crime (inerentes à espécie); circunstâncias do crime (considerando que além de grande quantidade de droga, foram apreendidas 03 (três) peneiras, 02 (duas) balanças de precisão, enorme quantidade de invólucros vazios comumente utilizado para armazenar drogas em porções individuais e 08 garrafas contendo a substância TRICLOROETILENO, constante na lista B1 (lista das substâncias psicotrópicas) e D2 (lista de insumos químicos utilizados para a fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos sujeitos a controle do Ministério da Justiça) da Portaria ANVISA 344/98 e atualizações posteriores - laudo pericial de fls. 253/255 -, majoro a pena em 1/6); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar); quantidade da droga (aumento a pena do acusado em 1/4, considerando que o acusado foi surpreendido com expressiva quantidade e diversidade de drogas, consistente em 29.5 kg de cocaína, volume extremamente valioso e suficiente para sustentar o vício de milhares de usuários, considerando que cada porção individual pesa aproximadamente 1g, além de diversas outras porções de cocaína, crack e maconha); natureza da droga (tendo em vista que as investigações demonstraram que o réu traficava maconha, cocaína e crack e, considerando que numa escala de ofensividade o crack está à frente da cocaína que, por sua vez, está à frente da maconha, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade de majorar em 1/4 quando se tratar de crack e em 1/6 quando se tratar de cocaína, não merecendo majoração quando se tratar de maconha. Portanto, valoro essa circunstância negativamente em 1/4).

Assim, fixo a pena base em 2/3 (1/6+1/4+1/4) acima do mínimo legal, ou seja, em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não verifico a incidência de circunstâncias agravantes.

Presentes as circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa, reduzo a pena em 1/3, considerando 1/6 para cada atenuante, fixando a pena em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Explico. O Min. Luiz Fux, no julgamento do Habeas Corpus nº 104.195, afirmou que "(...) Com o fito de minimizar sobre as pessoas que não se dedicam ao tráfico, mas

que por uma ou outra circunstância se viram envolvidas nesse crime, o legislador inseriu, na Lei de Entorpecentes, a causa especial de diminuição da pena de que trata o seu §4º do artigo 33. E assim o fez considerando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, numa visão de que não é razoável nem proporcional que o traficante circunstancial de pequena quantidade de entorpecente tenha o mesmo tratamento penal dispensado ao grande e habitual traficante de drogas. Desse modo, entre o intervalo de 1/6 a 2/3, previstos no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, o juiz aplicará a redução que entender necessária, sempre observando as peculiaridades do caso concreto”.

Tal ensinamento corrobora o entendimento da Min. Carmem Lúcia, conforme decisão lançada no Habeas Corpus nº 97.510-AC, do Supremo Tribunal Federal, na qual afasta qualquer ofensa ao princípio da proporcionalidade na aplicação da redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Anoto que a Lei nº 11.343/06 aumentou a pena mínima do crime de tráfico de drogas mas, em contrapartida, criou uma situação mais favorável aos traficantes primários, cuja aplicação pelo vocábulo "poderá" é facultativa.

Sendo assim, embora o acusado seja primário, tenha bons antecedentes e não existam provas de que faça parte de organização criminosa, restou evidente que se dedicava à atividade criminosa.

Isso porque, foi encontrado com 29,5 Kg de cocaína e 403 porções individuais de drogas variadas (maconha, cocaína e crack), quantidade enorme para quem é novo na traficância, além de petrechos e substância utilizada como insumo.

Nesse sentido, observa-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a circulação de expressiva quantidade de entorpecente pelo agente evidencia sua habitualidade delitiva, autorizando o afastamento do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Nesse sentido:

“(...) Esta Corte tem entendimento firme de que é possível a aferição da quantidade e da natureza da substância entorpecente, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria, para exasperar a pena-base e, na terceira, para justificar o afastamento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 - quando evidenciado o envolvimento habitual do agente no comércio ilícito de entorpecentes - sendo tal hipótese distinta da julgada, em repercussão geral, pela Suprema Corte no ARE 666.334/AM. (...) (STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 549.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 09/06/2020 - tese 46).

Ainda, no REsp nº 1.773.834, por unanimidade de votos decidiu “que a elevada quantidade de drogas apreendidas pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação a atividades delituosas, comportando, todavia, prova em sentido contrário.”

Assim, torno definitiva a pena do acusado em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena nos termos do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 c/c artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal c/c o artigo 42, da Lei 11.343/06, considerando se tratar de crime equiparado a hediondo, as circunstâncias negativas atinentes ao crime de tráfico de drogas, mais especificamente, natureza e a quantidade abundante da droga, além da apreensão de petrechos e insumos destinados ao tráfico de drogas que exigem a fixação do regime mais rigoroso para início do cumprimento de pena para uma correta prevenção criminal.

Considerando a pena aplicada, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e nem em relação à suspensão condicional da pena (artigo 77, do Código Penal).

MATHEUS AUGUSTO ROSSI

No tocante ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar

significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado é primário, não possuindo antecedentes criminais dignos de registro); conduta social (nada a considerar); personalidade (não há elementos para aferir eventual personalidade nociva do réu); motivos do crime (inerentes à espécie); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar); quantidade da droga (aumento a pena do acusado em 1/6, considerando que o acusado foi surpreendido com expressiva quantidade e diversidade de drogas, consistentes em 243 porções de cocaína, 38 porções de crack, 165 porções de maconha, suficientes para sustentar o vício de pelo menos 446 pessoas – considerando o total de porções individuais); natureza da droga (tendo em vista que as investigações demonstraram que o réu traficava maconha, cocaína e crack e, considerando que numa escala de ofensividade o crack está à frente da cocaína que, por sua vez, está à frente da maconha, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade de majorar em 1/4 quando se tratar de crack e em 1/6 quando se tratar de cocaína, não merecendo majoração quando se tratar de maconha. Portanto, valoro essa circunstância negativamente em 1/4).

Assim, fixo a pena base em 5/12 avos ($1/6 + 1/4$) acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 708 (setecentos e oito) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não verifico a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento de pena.

No entanto, incide a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Explico. O Min. Luiz Fux, no julgamento do Habeas Corpus nº 104.195, afirmou que "(...) Com o fito de minimizar sobre as pessoas que não se dedicam ao tráfico, mas que por uma ou outra circunstância se viram envolvidas nesse crime, o legislador inseriu, na Lei de Entorpecentes, a causa especial de diminuição da pena de que trata o seu §4º do artigo 33. E assim o fez considerando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, numa visão de que não é razoável nem proporcional que o traficante circunstancial de pequena quantidade de entorpecente tenha o mesmo tratamento penal dispensado ao grande e habitual traficante de drogas. Desse modo, entre o intervalo de 1/6 a 2/3, previstos no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, o juiz aplicará a redução que entender necessária, sempre observando as peculiaridades do caso concreto".

Tal ensinamento corrobora o entendimento da Min. Carmem Lúcia, conforme decisão lançada no Habeas Corpus nº 97.510-AC, do Supremo Tribunal Federal, na qual afasta qualquer ofensa ao princípio da proporcionalidade na aplicação da redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Anoto que a Lei nº 11.343/06 aumentou a pena mínima do crime de tráfico de drogas mas, em contrapartida, criou uma situação mais favorável aos traficantes primários, cuja aplicação pelo vocábulo "poderá" é facultativa.

Sendo assim, embora o acusado seja primário, tenha bons antecedentes e não existam provas de que faça parte de organização criminosa ou se dedique à atividade criminosa, os Policiais afirmaram que prenderam o acusado em local conhecido como ponto de venda de drogas e com grande quantidade de entorpecentes, indicando certa habitualidade, revelando que não se tratava de uma primeira incursão no mundo do tráfico.

Assim, tenho que a redução deve ser no padrão intermediário de 1/2 (metade) em respeito ao princípio da individualização da pena.

Assim, torno definitiva a pena para o crime de tráfico de drogas em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 354 (trezentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", c.c. art. 59, ambos do Código Penal, considerando o montante de pena aplicado.

Considerando a grande quantidade de drogas apreendida com o acusado, verifico que

não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e nem em relação à suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido da ação penal, e assim o faço para:

CONDENAR o réu MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA PADILHA ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; e

CONDENAR o réu MATHEUS AUGUSTO ROSSI ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 354 (trezentos e cinquenta e quatro) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, conforme fundamentado acima, por estar incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

c) ABSOLVER ambos os réus dos crimes capitulados no artigo 33, §1º, inciso I, e no artigo 34, ambos da Lei nº 11.343/06, imputados na denúncia, nos termos do art. 386, inc. V, do Código de Processo Penal, quanto ao réu MATHEUS AUGUSTO ROSSI, e do art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal, quanto ao acusado MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA PADILHA.

Estando os réus soltos e não havendo pedido para decretação da suas prisões preventivas, defiro o direito de recorrerem em liberdade.

Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e do art. 63 da Lei de Drogas, determino o PERDIMENTO em favor da União dos valores e demais bens apreendidos com os acusados.